

제38장

# 공시최고절차

## 1. 총 설

### 가. 의 의

‘공시최고’란 법원이 당사자의 신청에 의해 불특정 또는 불분명한 상대방에 대하여 권리 또는 청구의 신고를 최고하고 그 신고가 없을 때에는 실권의 효력이 생길 수 있다는 취지의 경고를 붙여 공고하는 재판상의 최고를 말하고, 이러한 최고에 의하여 경고한 실권을 제권판결로써 선고하는 절차가 공시최고절차이다.

법원이 행하는 절차인 점, 불특정 또는 불분명한 상대방에 대하여 하는 절차인 점(다만 후술과 같이 행방불명인 특정의 상대방에 대하여도 공시최고가 인정되는 경우가 있다), 실권의 경고를 붙여서 발하는 점의 3가지 특성이 모두 있다는 점에서 유사한 다른 절차(최고·공고 또는 상법 144조가 말하는 공시최고 등)와 구별된다.

공시최고는 권리 또는 청구의 신고를 하지 아니하면 실권될 것을 법률로 정한 경우에만 할 수 있다(민소 475조). 따라서 사인 간의 계약이나 회사의 정관에 대하여는 행할 수 없다.

### 나. 종 류

#### (1) 증권 또는 증서의 무효선고를 위한 공시최고

유가증권의 성질을 가진 대부분의 증권이 제권판결의 대상이 된다. 지시채권(민법 521조), 무기명채권(524조, 521조), 지명소지인출급채권(525조)의 채권증서가 멸실되었거나, 소지인의 점유를 이탈한 때에는 공시최고절차를 거쳐 그 채권증서를 무효로 할 수 있다. 그에 따라 약속어음(어음법 77조, 11조, 다만 약속어음 공정증서의 점유가 상실된 경우에 그 약속어음에 대한 공시최고 신청은 가능하지만, 공정증서 부분은 공시최고의 대상이 아니다), 수표(수표법 14조), 창고증권(상법 157조, 130조), 화물상환증(130조), 선하증권(861조) 등 유가증권의 성질을 가지는 대부분의 증권에 관하여 공시최고가 인정된다. 주

권에 관해서도 공시최고가 인정된다(360조).

이들 외에 징발보상증권(징발재산정리에관한특별조치법 9조, 11조), 농지채권, 도로국채, 남북협력기금채권 등도 제권판결의 대상이 된다.

그러나 면책증권에 불과한 시멘트 출고의뢰서(대법원 1981. 2. 27. 자 81마 55 결정)나 기명채권을 표시하는 증권에 불과한 농지개혁법(농지법으로 폐지)상의 지가증권(대법원 1961. 11. 23. 선고 60다478 판결)은 유가증권이 아니므로 이의 무효선고를 위한 공시최고신청을 할 수 없다. 차용증이나 계약서, 이를 인증한 공정증서 등도 하나의 증거증권에 불과하여 역시 무효선고를 위한 공시최고의 대상이 될 수 없다.

발행인의 기명날인 내지 서명이 없는 어음·수표는 어음·수표용지에 불과하고 유가증권이라 할 수 없으므로 유가증권에 대한 공시최고신청이 있을 경우 적어도 발행인의 기명날인 내지 서명이 있었느냐의 여부를 조사하여야 하고, 만약 발행인의 기명날인이 없다면 공시최고를 불허하여야 한다.

## (2) 등기·등록의 말소를 위한 공시최고

등기권리자가 등기의무자의 행방불명으로 인하여 등기의무자와 공동으로 어느 등기의 말소를 신청할 수 없을 때에 공시최고절차를 거쳐 제권판결을 얻어 그 등본을 첨부하여 등기권리자 단독으로 그 말소등기신청을 하는 경우(부등 56조)이다. 위와 같은 경우 등기권리자는 소를 제기하고 공시송달에 의하여 판결을 얻는 방법으로도 목적을 이룰 수 있으나 등기의 말소를 요하는 경우에는 보다 간편한 절차를 허용해 주기 위하여 규정된 제도이다(그러나 실무상으로는 대부분 전자의 방법으로 처리되고 있다). 부동산등기의 경우뿐만 아니라 선박등기(선박등기법 5조), 자동차 등 특정동산 저당권등록(자동차 등 특정동산 저당법 시행령 6조 2항 1호), 광업등록(광업등록령 64조 1항), 어업등록, 양식업등록(어업·양식업등록령 68조 1항), 특허권 등의 등록(특허권 등의 등록령 45조 1항), 품종보호등록(식물신품종 보호법 제52조에 따른 품종보호 등록에 관한 규칙 41조), 사채 등의 등록(은행법 시행령 19조의7) 등 각종 등기·

등록에 관하여도 당해 법령에 유사한 규정이 있다.

### (3) 기타 공시최고

이 밖에 민법 27조와 가사소송법 2조 1항 2호 (가)목 3), 가사소송규칙 53조에 의하여 실종선고를 함에 있어서는 공시최고를 요하지만, 이 절차에 관하여는 가사소송규칙 54조 이하에 특별규정이 있으므로 민사소송법의 공시최고절차 규정이 직접 적용되지 않는다. 또한 부재선고에 관한 특별조치법은 미수복지구의 잔류자에 대한 부재선고에 있어서도 공시최고를 하도록 하고 있는데, 위 부재선고의 절차에는 가사소송법의 실종에 관한 규정이 준용되므로(8조, 9조) 역시 민사소송법상의 공시최고절차 규정이 직접 적용되지 않는다.

### 다. 적용 규정

민사소송법은 475조 내지 491조에서 위 (1), (2)항의 경우에 공통 적용되는 총칙적 규정을 둔 다음 492조 이하에서 전자의 경우(증권 또는 증서의 무효선고를 위한 공시최고)에만 적용되는 특칙을 두고 있다. 실무상 공시최고 가운데 거의 대부분이 유가증권의 무효선고를 위한 공시최고이다.

## 2. 관할법원

공시최고는 법률에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 실권될 권리자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원이 관할한다(민소 476조 1항 본문). 그리고 등기 또는 등록을 말소하기 위한 공시최고는 그 의무자의 주소지 법원 외에 그 등기 또는 등록을 한 공공기관(등기소·특허청 등)이 있는 곳의 지방법원에도 신청할 수 있다(단서). 그러나 증권 또는 증서의 무효선고를 위한 공시최고의 경우에는 대체로 실권될 자를 전혀 알 수 없으므로 공시최고의 대상이 되는 증권이나 증서에 이행지(어음·수표의 지급지, 화물상환증의 도착지, 창고증권의 보관장소)의 표시가 있을 때에는 그 이행지의 지방법원, 그 표시가 없을

때에는 발행인의 보통재판적(주권의 경우 회사의 본점소재지)이 있는 지방법원, 그 법원이 없는 때에는 발행인의 발행 당시에 보통재판적이 있던 곳의 지방법원이 관할하며(2항), 이는 모두 전속관할이다(3항). 전속관할 위반은 공시최고의 경우 제권판결에 대한 불복소송의 사유로 되어 있다(490조 2항 5호).

지방에 본점을 두었지만 전국 규모의 대기업인 회사의 주식에 대한 공시최고신청을 서울에서 하는 경우가 있는데, 이는 잘못된 것이므로 주의를 요한다. 예컨대 주식회사 포스코(구 포항제철주식회사)의 주권에 대한 공시최고신청은 서울중앙지방법원의 관할이 아니고 대구지방법원 포항지원의 관할이다. 본점 주소지가 기록상 나타나지 않는 경우 발행회사의 법인등기사항증명서의 제출을 명하여 관할을 확인하여야 한다.

법원조직법 32조 1항 2호, ‘민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙’은 공시최고사건을 지방법원이나 지방법원 지원의 합의부가 심판할 사항으로 열거하고 있지 아니하므로 공시최고사건은 단독판사가 담당하게 된다(법조 7조 4항). 또한 법원조직법 34조는 공시최고사건을 시·군법원이 관할할 사건으로 열거하고 있지 아니하므로 시·군법원은 공시최고사건에 대한 관할권이 없다.

법원조직법 개정에 따라 2005. 7. 1. 이후에 접수된 사건부터는 사법보좌관도 민사소송법 477조 내지 479조의 규정에 따른 공시최고에 관한 법원의 사무, 즉 공시최고절차 중 공시최고의 허부에 관한 법원의 사무를 담당할 수 있게 되었다(사법보좌관규 2조 1항 3호). 그 사무는 구체적으로 관할, 공시최고의 대상이 되는 증권인지 여부, 도난사실 및 증권의 발급사실에 대한 소명자료의 확인 및 공시최고의 공고 등이며, 사무의 성질상 쟁송적 성격이 없으므로 사법보좌관의 업무로 한 것이다. 다만 공시최고절차 중 제권판결은 사법보좌관의 업무에서 제외되고, 공시최고기일의 실시도 제권판결 선고와 동시에 이루어지고 있으므로 사법보좌관의 업무에서 제외되었다.

### 3. 신청 및 접수

#### 가. 신청권자

등기·등록의 말소를 위한 공시최고의 경우 누가 공시최고의 신청권자인지는 별다른 문제가 없다. 증권이나 증서의 무효선언을 위한 공시최고의 경우 신청권자는 증권 또는 증서를 도난당하거나 증서가 분실·멸실된 사람이다(민법 521조, 민소 492조 1항). 즉 증권을 상실하지 아니하였더라면 그 증권에 의하여 권리를 행사할 수 있는 최종소지인이다(대법원 1970. 11. 24. 자 70마694 결정). 따라서 증서를 횡령 또는 사기당한 자는 공시최고를 신청할 수 없다(대법원 1989. 7. 11. 선고 87다카2445 판결, 대법원 2016. 10. 27. 선고 2016다235091 판결). 증권 또는 증서의 소지인을 알면서도 그 소재를 모르는 것처럼 공시최고신청을 하여 제권판결을 받았다면, 이는 민사소송법 490조 2항 7호에 정한 ‘거짓 또는 부정한 방법으로 제권판결을 받은 때’에 해당한다(대법원 1997. 7. 25. 선고 97다16985 판결).

도난·분실·멸실의 사실은, 실무상 신문지상의 분실광고나 경찰관서의 도난신고 증명서로써 소명한다.

#### 나. 신청방식

신청은 서면으로 하여야 하며(민소 477조 2항), 말로 신청하는 것은 허용되지 않는다. 법원사무관리규칙 66조 2항 및 67조에 따라 각급 법원에는 공시최고신청서[전산양식 A2380] 서식을 작성·비치하도록 되어 있다(민사신청서양식에 관한 예규).

#### 다. 신청서 기재사항 및 소명

신청서에는 신청의 이유와 제권판결을 구하는 취지를 명시하여야 한다(민소 477조 1항). 소명은 일반 원칙에 따라 신청인 또는 법정대리인으로 하여금 보증금을 공탁하게 하거나 진실함을 선서하게 하여 갈음할 수 있다(299조 2항).

### (1) 증권 또는 증서의 무효선고를 위한 공시최고

신청의 이유로서는 그 증권 또는 증서가 멸실 또는 점유이탈(도난·분실)되었다는 사실을 적어야 한다.

신청의 이유 소명에 대하여는 민사소송법 494조에 특별규정이 있다. 즉 이 경우에는 ① 증권 등의 등본을 제출하거나 증권 등의 존재 및 그 중요한 취지를 충분히 알리기에 필요한 사항을 적어서 제출하여야 하고(보통은 증권 등이 존재하지 아니하여 등본 작성이 불가능하므로 후자의 방식에 의하고 있다), ② 증권 등이 없어지거나 점유이탈(도난·분실)된 사실을 소명하여야 하며(보통은 신문에 분실광고를 하고 이를 복사하여 제출하거나, 경찰서에 도난·분실신고를 하여 그 도난·분실신고접수증을 제출하거나 또는 소방관서의 화재증명서를 제출하는데, 도난신고접수증과 화재증명서는 그 도난·화재장소를 관할하는 관서에서만 발급하여 주고 있다), ③ 공시최고신청의 권리가 있는 사실, 즉 신청인이 그 증권 등의 최종소지인 기타 권리자임을 소명하여야 한다(이 소명을 위해서는 기명식증권의 경우에는 그 등본 또는 발행인의 증명서에 의하여 신청인이 수취인·피배서인 등으로 기재된 사실을 소명하면 될 것이나, 무기명식증권의 경우에는 위와 같은 엄격한 소명을 하기 어려운 경우가 많으므로 막연히 발행증명서에 최종소지인을 신청인으로 기재하여 발행인의 증명을 받아 제출하고 있다).

다만 약속어음이나 당좌수표(가계수표 포함)의 발행인이 예금부족 등의 사유로 부도처리됨으로써 거래정지처분 등 금융제재조치를 받게 되자 이를 해결하기 위한 수단으로 부도된 어음·수표를 회수하지 아니하고 제권판결을 받아 실권시키려는 경우가 종종 있다. 따라서 신청인 발행의 유가증권에 대한 공시최고신청이 있는 경우 그 증권이 은행에 지급제시되었는지 여부에 관하여 지급은행에서 발급한 자료(이른바 미제시증명서)에 의해 소명할 것을 명한다. 신청인(발행인) 이외의 제3자에 의해 지급제시되었다가 부도처리된 경우에는 신청인(발행인)이 그 지급제시인으로부터 그 증권을 회수하였었다는 지급제시인 작성의 회수증명서를 제출하라는 보정명령을 한다. 다만 자

기앞수표의 공시최고신청의 경우에는 미제시증명서가 아닌 미지급증명서가 제출됨으로써 족하다. 이와 같이 그 증권들이 분실·도난되었는지 여부를 확인한 다음 공시최고허가를 하여야 한다.

## (2) 등기·등록의 말소를 위한 공시최고

신청의 이유로는 그 등기·등록의 기초된 권리가 실체상으로 소멸하였는데도 등기부·등록부 위에 그대로 등재되어 있다는 것과 등기·등록의무자가 행방불명되어 함께 말소등기·등록을 신청할 수 없다는 사실을 적어야 한다.

신청의 이유를 소명하기 위해서는 당해 등기사항증명서 기타 등기·등록부 등본과 권리소멸을 소명할 서류(임차권등기말소의 경우에는 임대차계약서와 해지통고서 등), 행방불명을 소명할 서류(주민등록표등본 등)를 제출하여야 한다.

## 라. 인지의 첨부 및 비용의 예납 등

(1) 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 9조 5항 1호).

(2) 신청에 있어서는 절차의 진행에 필요한 비용을 예납하여야 한다.

후술 공시최고기일의 통지에 필요한 1인×2회분과 제권판결의 송달에 필요한 1인×1회분, 도합 1인×3회분의 송달료를 예납받는다(송달료예규).

(3) 그 밖에 공시최고서 작성, 제권판결 작성 등에 사용하기 위하여 증권 또는 증서의 중요한 취지 또는 말소대상등기·등록의 표시를 기재한 서면을 적당한 수만큼 제출하는 것이 관례이다. 그러나 이 사본 제출이 없다고 해도 그 제출을 권고할 수 있을 뿐이지 접수를 거부하거나 신청을 각하할 수는 없다. 사본이 없을 때에는 법원에서 작성하여야 한다.

## 마. 접 수

공시최고신청서는 공시최고사건으로 전산입력하여 접수하고(인지액·편철 방법예규), 사건부호(‘카공’)를 붙여 사건번호를 부여한 다음 독립의 표지[전산양식 A1012]를 붙여 기록을 조제한다.

법원사무관등이 신청서를 접수할 때 당사자능력, 소송능력, 관할, 인지 첨부 유무, 기타 신청서의 필수적 기재사항 등을 조사하고, 보정사항을 지적하여 구비하게 한다. 절차비용은 예납명령을 기다릴 것 없이 적극적으로 납부하게 한다. 이에 따르지 않는 경우 법원은 상당한 기간을 정하여 흠의 보정을 명하고, 신청인이 정해진 기간 안에 흠을 보정하지 아니한 때에는 명령으로 공시최고신청서를 각하하여야 한다. 이 각하명령에 대하여는 즉시항고가 허용된다(민소 254조 유추적용).

#### 4. 공시최고

##### 가. 허부의 결정

(1) 법원은 직권으로 신청내용이 공시최고를 할 사유에 해당하는지 여부를 조사하여야 한다. 증권 등의 무효선고를 위한 공시최고의 경우 신청을 허용할 증권이나 증서일 것, 그 증권 등이 도난·분실 또는 멸실된 것일 것, 신청인에게 신청권을 인정할 수 있을 것 등을 조사하며, 등기·등록의 말소를 위한 공시최고의 경우 말소될 등기·등록된 권리가 실체상 소멸되고, 의무자가 행방불명된 것이 소명되었는가를 조사한다. 필요한 때에는 신청인을 심문할 수 있고(민소 478조 2항) 제3자를 심문할 수도 있다.

(2) 조사결과 신청이 이유 없거나 부적법한 때에는 공시최고를 허가하지 아니한다는 결정을 하여야 한다(민소 478조 1항 전문). 주문의 형식은 “이 사건에 관하여 공시최고를 허가하지 아니한다.”로 될 것이고 이유를 붙여야 한다. 이 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(후문). 공시최고의 요건에 흠이 있음에도 이를 간과하고 공시최고를 허가한 때에는 제권판결에 대한 불복소송의 사유가 된다(490조 2항 1호). 즉 증권 등을 횡령 또는 편취당하였음을 이유로 공시최고신청을 하였는데, 법원이 이를 간과하여 제권판결을 한 경우는, 민사소송법 490조 2항 1호의 ‘법률상 공시최고절차를 허가하지 아니할 경우일 때’에 해당한다(대법원 1989. 7. 11. 선고 87다카2445 판결).

(3) 신청이 적법하고 이유 있다고 인정한 때에는 공시최고를 허가하는 결정을 하도록 규정되어 있는데(민소 478조 1항 전문), 실무에서는 따로 결정서를 만들지 아니하고 공시최고서에 그 결정취지를 기재하고 있다.

## 나. 공시최고의 방법

### (1) 기재사항

공시최고에 적어야 할 사항은 민사소송법 479조 2항과 495조에 규정되어 있는데, 전자는 모든 공시최고에 관한 통칙적 규정이고 후자는 증권 등의 무효선고를 위한 공시최고에 관하여 이를 특칙화한 규정이다.

먼저, 모든 공시최고에서 신청인의 표시(민소 479조 2항 1호)와 후술 공시최고기일의 일시(4호)를 기재하여야 하고, 그 공시최고기일까지 권리 또는 청구의 신고를 하여야 하다는 최고의 문구(2호)와 그 신고를 하지 않았을 경우 권리를 잃게 될 사항이 무엇인지(3호)를 명시하여야 한다. 특히 증권 등의 무효선고를 위한 공시최고에서는 권리나 청구의 신고와 함께 그 ‘증서의 제출’을 최고하고 이를 게을리하면 권리를 잃게 되어 증권 등의 무효가 선고된다는 것을 경고하도록 요구하고 있다(495조).

공시최고의 두 가지 유형 중 증권 등의 무효선고를 위한 공시최고의 양식은 [전산양식 A2381]에, 등기·등록의 말소를 위한 공시최고의 양식은 [전산양식 A2382]에 각 규정되어 있으므로 이에 따르면 된다.

[전산양식 A2381] 공시최고(증서)

○○포유

공시최고

사 건 20〇〇카공〇〇 공시최고  
 신 청 인 〇〇〇  
 서울 〇〇구

별지 기재 증서의 소지인은 공시최고기일인 20 . . . : 까지 이 법원에  
권리 또는 청구의 신고를 하고 그 증서를 제출하기 바랍니다. 만일 이를 게을리  
하면 권리를 상실하여 증서의 무효가 선고될 수 있습니다.

2000. 0. 0.

판 사 ㉠

### 〈별지 기재례〉

## 증서의 중요한 취지

종 류 자기앞 수표  
번 호 나2331689  
액 면 금 5,000,000원  
발행일 2000. 5. 10.  
발행인 00은행 00지점

[전산양식 A2382] 공시최고(부동산등기)

○○포인

공시최고

사 건 20○○카공○○ 공시최고  
 신 청 인 ○○○  
 (등기권리자) 서울 ○○구  
 등기의무자 ○○○  
 현재 행방불명  
 등기부상 주소

신청인의 이 사건 공시최고신청을 허가하는바, 위 등기의무자는 공시최고기일인 20 . . . : 까지 이 법원에 다음 기재 등기의 말소등기에 관한 권리 또는 청구의 신고를 하기 바랍니다. 만일 이를 게을리하면 위 말소등기에 관하여 실권이 선고되는 수가 있습니다.

[말소대상 등기의 표시]

서울 종로구 윤니동 300 지상

철근 콘크리트조 슬래브지붕 2층 점포 1동

1층 45m<sup>2</sup>

2층 45m<sup>2</sup>에 관하여

○○지방법원 20○○. ○. ○. 접수 제 호로 경료한 저당권설정등기

2000. 0. 0.

사법보좌관

인

## (2) 공고

공시최고는 대법원규칙이 정하는 바에 따라 공고하여야 하는데(민소 480조), 민사소송규칙 142조 1항은 공시최고의 공고 방법으로 법원게시판 게시(1호), 관보·공보 또는 신문 게재(2호), 전자통신매체를 이용한 공고(3호) 중 어느 하나의 방법으로 하되, 필요하다고 인정하는 때에는 적당한 방법으로 공고사항의 요지를 공시하도록 규정하였다. 그런데 공고방법예규 3조는 위

공시최고의 공고는 공고사항을 법원 홈페이지 공고란에 게시하는 방법으로 하도록 정하고 있다.

공시최고기일은 이 공고가 끝난 날부터 3월 뒤로 정하여야 한다(민소 481조).

법원사무관등은 공고한 날짜와 방법을 기록에 표시하여야 한다(민소규 142조 2항).

## 5. 권리 또는 청구의 신고

(1) 권리 또는 청구의 신고는 공시최고의 다음 단계로 행해지는 제권판결을 저지하기 위하여 당해 증권 등의 소지인 기타 이해관계인(증권 등의 무효선고를 위한 공시최고의 경우) 또는 등기·등록의무자(등기·등록의 말소를 위한 공시최고의 경우)가 하는 절차적 행위이다.

전자의 경우에는 보통 신고인이 당해 증권 등을 소지하고 있다든가 증권에 관한 실질적 권리가 있다든가 공시최고의 요건이 흠결되었다든가 하는 사유를 주장하게 될 것이고, 후자의 경우에는 등기·등록의무자가 행방불명이 아니라 어느 특정 주소에 거주하고 있다는 사실을 주장하면 될 것이다.

(2) 이 신고의 방식에는 특별한 제한이 없으므로 서면 또는 말로 할 수 있다(민소 161조 1항). 말로 하는 신고에 대한 조서 기재방식에 대하여는 제36장(제소전화해) 3. 가. 참조.

권리 또는 청구의 신고서에는 인지의 첨부을 요하지 아니하고(인지액·편철 방법예규), 서면의 신고 등이 있으면 문건으로 전산입력하여 접수하면 된다.

어느 경우든 권리를 주장하면 족하고 증명할 필요까지는 없으며, 법원도 그 권리의 존부나 실체상의 이유 유무까지 나아가 조사할 필요가 없다. 다만 증권 등의 무효선고를 위한 공시최고에서는 신고시에 해당 증권 등을 제출할 것을 요하는데(민소 495조), 이는 신고인이 ‘정당한’ 소지인임의 증명을 요구하는 취지가 아니라 단순히 증권 등의 소재를 확인하기 위한 것이라고 설명된다. 실무상으로는 접수창구에서만 증권 등을 확인한 후 그 사본을 제출

받아 이를 공시최고 사건기록에 편철하고 있다.

(3) 권리신고나 청구는 공시최고기일까지 하는 것이 원칙(위 공시최고의 기재사항 참조)이지만 이를 경과하였더라도 제권판결이 선고되기 전까지만 하면 실권되지 않는다(민소 482조). 실무상 신청인이 공시최고기일에 출석하면 그 기일에 제권판결을 선고하는 것이 보통인데, 그 경우에는 위 조문이 적용될 여지는 없고, 신청인이 공시최고기일에 출석하지 아니하거나 기일변경신청을 하여 다시 지정된 새 기일에 제권판결을 한다든지 법원이 공시최고기일에 제권판결을 선고하지 아니하고 제권판결 선고기일을 달리 정한 경우에 위 조문이 적용될 여지가 있다.

따라서 이러한 경우에는 제권판결을 할 수 없게 되거나 후술의 보류부 제권판결을 하게 된다.

(4) 권리신고나 청구는 당해 공시최고절차 내에서 하여야 하며 가령 공시최고절차가 계속되어 있는 법원의 일반 재판부에 그 권리에 관한 소를 제기하였다 하여도 권리 또는 청구의 신고에 해당하지 않는다(대법원 1976. 7. 13. 선고 75다1009 판결). 따라서 제권판결이 있기 전에 어음·수표소지인이 지급은행에 지급 제시를 하거나, 어음금·수표금지급 청구 소송을 제기하였다 하여도 이를 공시최고법원에 대한 권리의 신고나 청구로 볼 수 없다(대법원 1983. 11. 8. 선고 83다508 판결).

## 6. 공시최고기일의 시행

공시최고의 공고가 다 마쳐지고 지정된 공시최고기일이 가까워지면 신청인에게 기일통지서를 송달하여 출석하게 하여야 한다. 그러나 권리신고인이거나 등기·등록의무자는 출석을 요하지 아니한다.

신청인이 기일에 불출석하거나 기일변경신청을 하는 때에는 1회에 한하여 새 기일을 정하여 주어야 한다(민소 483조 1항). 이 새 기일은 원래의 기일로 부터 2월을 넘기지 아니하여야 하며 공고할 필요가 없다(2항). 이 새 기일에

도 신청인이 불출석하면 공시최고신청을 취하한 것으로 간주된다(484조).

신청인이 공시최고기일에 출석하면 제권판결을 구하는 취지 및 신청의 이유를 진술하게 된다(민소 486조). 진술간주제도(148조)는 이 절차에서 적용되지 않는다.

### [전산양식 A2383] 공시최고조서

#### ○ ○ 법 원

#### 공시최고조서

제 1 차

사 건 20○○카공101 공시최고

판 사 ○○○

법원주사 ○○○

기 일 20 . . . . :

장 소 ○○호 법정

공개 여부 공 개

사건과 당사자를 호명

신청인 ○○○

출석

신청인

공시최고 신청서를 진술하고, 소명으로 미지급증명, 분실공고를 원용

종결

판결선고

법원주사 ○○○ 인

판 사 ○○○ 인

또 제권판결을 필요로 하는 사실(신청의 이유)에 관한 증명(소명)을 하여야 한다. 이는 상대방이 없는 절차이므로 직권주의가 적용된다(민소 487조 2항).

법원은 신청이 이유 있다고 인정하면 후술의 제권판결을 선고하여야 하고, 이유 없다고 인정하면 신청각하의 결정을 하여야 한다(민소 487조 1항).

공시최고기일의 조서 기재례는 [전산양식 A2383]과 같다.

## 7. 제권판결

### 가. 의 의

‘제권판결’이란 공시최고절차의 마지막 단계로서 신청 대상이 된 권리의 무효, 즉 실권의 효력을 발생시키는 형성적 재판이다. 구체적으로 말하면 전술의 두 가지 유형 중 증권 등의 무효선고를 위한 공시최고절차에서는 그 증권 등의 무효를 선고하게 되고, 등기·등록의 말소를 위한 공시최고절차에서는 말소등기의 대상이 될 등기·등록에 관하여 등기의무자가 실권되었음을 선고하게 될 것이다.

### 나. 제권판결을 하지 아니하는 경우

(1) 공시최고기일에서의 심리에 의하여 신청이 이유 없다고 인정하면 결정으로 제권판결신청을 각하하게 되는데, 물론 이때는 제권판결을 하지 아니한다(결국 공시최고신청의 당부에 대하여는 공시최고를 발할 것인지 여부를 결정하는 단계와 공시최고기일에 이르러 제권판결 여부를 정하는 단계의 2단계로 심리가 행해지는데 전자의 결정이 후자의 결정에 영향을 미치지 않음은 물론이다). 제권판결신청을 각하한 결정이나 제권판결에 덧붙인 제한 또는 유보에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민소 488조).

### (2) 증권 또는 증서의 무효선고를 위한 공시최고

공시최고신청이 이유 있다고 인정되면 권리 또는 청구를 다투는 신고가 있다고 해서 그 사유만으로 제권판결을 아니할 수 있는 것은 아니며 이때는 그 사정에 의하여(즉 신고된 권리나 청구의 내용에 의하여) 그 권리에 관한 재판의 확정 시까지 공시최고절차를 중지하는 취지의 결정을 하거나 또는 바로 제권판결을 하면서 신고인의 권리를 보류하고 신고인 외의 불특정 이해관계인에 대한 관계에서만 효력이 있는 제권판결(보류부 제권판결)을 하여야

한다(민소 485조).

전자의 경우, 즉 공시최고절차 중지의 결정을 한 경우에는 나중에 그 재판이 확정되면 속행결정을 한 다음 그 재판에 따라 공시최고신청을 각하하거나 제권판결(보류부 제권판결일 수도 있다)을 하게 된다. 그러나 실무상 중지결정을 하는 예는 드물고 대부분 보류부 제권판결을 함으로써 절차를 종결하고 있다.

### (3) 등기·등록의 말소를 위한 공시최고

공시최고신청 자체가 등기·등록의무자의 행방불명을 이유로 하는 것이므로 그 등기의무자가 자신의 주소를 표시하여 권리신고를 한 경우에는 신청의 기초가 흔들리게 된다. 따라서 신청인은 공시최고기일에서 신고인(등기·등록의무자)의 신고주소가 허위라는 등으로 여전히 행방불명 상태가 계속되고 있음을 소명하여야 하며, 그 소명을 못하는 한 제권판결을 얻을 수 없고 결국 신청을 각하당하게 될 것이다(즉 이 경우에는 재판확정시까지 절차중지라든가 보류부 제권판결이라는 것이 아무런 의미가 없다).

## 다. 양 식

증권 등의 무효선고를 위한 공시최고절차에서의 제권판결의 양식은 [기재례 1]과 같다. 또 권리신고가 있어 그 권리를 보류하는 경우에는 주문과 이유를 [기재례 2]와 같이 한다.

다음 실무상 그 예는 별로 많지 않으나 등기·등록의 말소를 위한 공시최고절차에서의 제권판결의 양식은 [기재례 3]과 같이 한다.

[기재례 1]

○ ○ 법 원

제 권 판 결

사 건 20○○카공101 공시최고  
신 청 인 ○○○ (        )  
서울 종로구 청계천로 60  
대리인 ○○○

주 문

별지 목록 기재 증서의 무효를 선고한다.

이 유

별지목록 기재 증서에 대하여 20○○. ○. ○. 공시최고를 하였는바 그 공시최고에  
서 정한 20○○. ○. ○. 10:00까지 권리의 신고나 청구 및 증서를 제출한 자가 없  
으므로 신청인의 신청에 의하여 주문과 같이 판결한다.

20○○. ○. ○.

판 사 ○○○ (인)

[기재례 2]

주 문

별지 목록 기재 증서에 대하여 신청외 ○○○(서울 강동구 천호대로197길 80)이  
신고한 권리를 보류하고 위 증서의 무효를 선고한다.

이 유

별지 목록 기재 증서에 대하여 20○○. ○. ○. 공시최고를 하였는바, 20○○. ○. ○.  
신청외 ○○○로부터 권리신고가 있으므로 주문과 같이 판결한다.

## [기재례 3]

## ○ ○ 법 원

## 제 권 판 결

사        건        20○○카공102 공시최고  
 신 청 인        ○○○  
 (등기권리자)    서울 종로구 청계천로 60  
 등기의무자     ○○○  
                   현재 소재불명  
                   등기부상 주소 서울 중구 장충동 200

## 주 문

별지목록 기재 등기의 말소등기에 관한 등기의무자의 실권을 선고한다.

## 이 유

별지목록 기재 등기의 말소등기에 대하여 20○○. ○. ○. 공시최고를 하였는바, 그 공시최고에서 정한 20○○. ○. ○. 10:00까지 등기의무자로부터 권리의 신고나 청구가 없으므로 주문과 같이 판결한다.

20○○. ○. ○.

판사    ○○○ (인)

## 라. 공고 및 정본송달

제권판결의 요지 역시 대법원규칙이 정하는 바에 따라 공고할 수 있는데 (민소 489조), 민사소송규칙 143조는 공시최고의 공고에 관한 민사소송규칙 142조를 준용하도록 규정하고 있다. 따라서 제권판결의 공고는 앞에서 본 법원게시판 게시, 관보·공보 또는 신문 게재, 전자통신매체를 이용한 공고 중 어느 하나의 방법으로 할 수 있는데, 공고방법예규 3조는 제권판결 요지의 공고도 공고사항을 법원 홈페이지 공고란에 게시하는 방법으로 한다고

정하고 있다.

제권판결을 공고한 경우에 법원사무관등은 공시최고의 공고의 경우와 같은 요령으로 공고한 날짜와 방법을 기록에 표시하여야 한다(민소규 143조, 142조 2항).

실무에서는 제권판결의 정보를 신청인에게 송달 또는 교부하여 주고 있다. 권리신고인에게는 송달하지 아니한다.

#### 마. 효 령

일반적으로 제권판결은 실권을 발생시키는 효력이 있다고 할 수 있으나 구체적으로는 공시최고의 유형에 따라 그 의미가 다르다.

##### (1) 증권 등의 무효선고를 위한 공시최고

제권판결에 의하여 소극적으로 그 증권 등이 무효로 되는 동시에(민소 496조), 적극적으로 공시최고신청인이 그 증권 등에 의한 채무자에 대하여 권리를 행사할 수 있게 된다(497조). 즉 그 증권 등 대신에 제권판결이 증권 등의 역할을 하게 된다.

예컨대 약속어음에 관한 제권판결의 효력은 그 판결 이후에 있어서 당해 어음을 무효로 하고 공시최고신청인에게 어음을 소지하는 것과 동일한 지위를 회복시킨다. 그러나 공시최고신청인이 실질상의 권리자임을 확정하는 것은 아니다. 다만 취득자가 소지하고 있는 약속어음은 제권판결의 소극적 효과로서 약속어음으로서의 효력이 상실되는 것이므로 약속어음의 소지인은 무효로 된 어음을 유효한 어음이라고 주장하여 어음금을 청구할 수 없다.

어음상 실질적 권리자도 제권판결의 효력을 소멸시키기 위하여 불복의 소를 제기하여 취소판결을 얻지 않는 한 어음상 권리 행사가 불가능하다(대법원 1990. 4. 27. 선고 89다카16215 판결). 이러한 이치는 공시최고의 신청인이 발행인인 경우와 발행인이 아닌 소지인(어음상의 권리자)인 경우에 따라 구별되는 것은 아니다(대법원 1994. 10. 11. 선고 94다18614 판결).

이 경우 제권판결 전에 그 증서를 선의취득한 사람과 제권판결을 얻은 사람 중 누가 우선하게 되는지가 문제 되고 학설은 대립되어 있는데, 판례는 제권판결취득자가 우선한다는 견해를 취하고 있다(대법원 1994. 10. 11. 선고 94다18614 판결). 이에 의하면 제권판결 선고 전에 선의취득자가 생겼고 공시최고신청인이 이를 알았다 하더라도 그 선의취득자가 공시최고법원에 권리신고를 하지 아니하여 일단 제권판결이 선고되어 버렸다면 그 선의취득자는 증서상의 권리를 행사할 수 없게 된다. 제권판결 이전에 주식을 선의취득한 자는 위 제권판결이 취소되지 않는 한 회사에 대하여 적법한 주주로서의 권한을 행사할 수 없으므로 회사의 주주로서 주주총회 및 이사회결의무효확인을 소구할 이익이 없다(대법원 1991. 5. 28. 선고 90다6774 판결).

## (2) 등기·등록의 말소를 위한 공시최고

제권판결에 의하여 신청인이 단독으로 말소등기·등록을 신청할 수 있게 된다. 즉 신청인은 등기신청서에 제권판결의 등본을 첨부하여 자기 혼자 이름으로 말소등기신청을 할 수 있다(부등 56조 2항).

## 8. 제권판결에 대한 불복의 소

### 가. 의 의

제권판결에 대하여는 상소를 하지 못하므로(민소 490조 1항), 제권판결은 선고와 동시에 확정된다. 그러나 그 판결에 중대한 위법이 있는데도 시정의 수단을 부여하지 않는다는 것은 정의에 반하므로 법은 일정한 사유가 있는 때에 한하여 불복의 소를 제기할 수 있도록 하고 있다(2항).

### 나. 제소의 사유

불복의 소는 민사소송법 490조 2항에 열거된 사유가 있는 경우에 한하여 허용되며, 이러한 각 사유에 해당하는 사실을 청구원인으로 하여 소를 제기하지 않으면 안 되고, 그렇지 아니하면 부적법한 소로서 각하를 면할 수 없

다. 제권판결에 대한 불복소송의 사유는 다음과 같다.

(1) 법률상 공시최고절차를 허가하지 아니할 경우일 때(1호)

법률이 공시최고를 할 수 있다는 근거규정을 두고 있지 않는데도 공시최고를 한 경우를 말한다. 다시 말하면 일반적·추상적으로 이를 인정하는 법규정이 전혀 없음에도 불구하고 공시최고를 한 경우를 의미하며, 개별적·구체적인 공시최고절차 내에서 한 사실인정이 부당한 경우를 의미하는 것이 아니다(대법원 1989. 5. 23. 선고 88다카16409 판결). 따라서 신청인이 약속어음의 최후 소지인도 아니고 이를 분실한 사실이 없음에도 불구하고 거짓신고를 하여 제권판결을 받았다는 주장은 제권판결에 대한 불복사유가 되지 못한다(대법원 1980. 10. 14. 선고 80다1731 판결). 신청인이 약속어음을 횡령 또는 사취당하였다고 주장하며 공시최고를 신청하였는데, 법원이 이를 간과하고 그대로 제권판결을 선고한 경우, 약속어음이 도난, 분실 또는 멸실된 경우에 해당하지 아니하여 추상적, 일반적으로 공시최고를 인정할 법률상 근거가 없는 것으로서 법률상 공시최고절차를 허가하지 아니할 때에 해당한다(대법원 1989. 7. 11. 선고 87다카2445 판결, 대법원 1991. 2. 26. 선고 90다17620 판결).

(2) 공시최고의 공고를 하지 아니하였거나 법령이 정한 공고의 방식에 위반한 때(2호)

공시최고의 공고를 전혀 하지 않은 채 제권판결을 한 경우 및 공고를 했더라도 공고할 사항(민소 479조 2항, 495조)을 누락하였거나 공고 방식에 관한 대법원규칙의 규정을 위배한 경우(민사소송규칙 142조가 정하는 세 가지 방식 외의 방식으로 공고한 경우)이다.

(3) 공시최고기간을 지키지 아니한 때(3호)

공고일과 지정된 공시최고기일 사이의 간격이 3월(민소 481조)에 미달하는 때이다.

(4) 제권판결을 한 판사가 법률에 따라 직무집행에서 제척된 때(4호)

(5) 전속관할에 관한 규정에 어긋난 때(5호)

## (6) 권리 또는 청구의 신고가 있음에도 제권판결을 한 때(6호)

법원에 제권될 염려 있는 권리나 청구가 존재함을 신고하였음에도 불구하고 그대로 제권판결을 한 때에는 그 판결에 대한 불복사유가 된다. 이 권리 신고 등은 당해 공시최고절차 내에서 하여야 하고, 공시최고법원이 아닌 다른 법원에 그 증서에 기한 청구소송을 제기한 것만으로는 청구 또는 권리의 신고가 있었다고 할 수 없다(대법원 1983. 11. 8. 선고 83다508 판결).

## (7) 거짓 또는 부정한 방법으로 제권판결을 받은 때(7호)

전 소지인이 증권 등의 소지인을 알면서도 소재를 모르는 것처럼 공시최고법원을 기망하여 제권판결을 받은 경우(대법원 1997. 7. 25. 선고 97다16985 판결), 증권을 소지한 사실이 없음에도 이를 소지하다가 도난당하거나 분실한 것으로 꾸며 공시최고를 신청하여 제권판결을 받은 경우(대법원 2011. 11. 10. 선고 2009다73868 판결) 등이 이에 해당한다.

전 소지인이 증권 등을 도난당하여 경찰서에서 조사를 받으면서 절도범으로부터 채권을 취득한 자를 그날 처음 보았고, 압수된 채권 중 어느 것이 전 소지인의 소유인지도 정확히 모르고 있었으며, 공시최고신청 당시에도 그날 함께 조사를 받은 자가 증권 전부를 소지하고 있었다는 점도 확실히 모르는 상태에서 공시최고신청을 하여 제권판결을 받은 경우(대법원 1997. 7. 25. 선고 97다16985 판결)나 공시최고신청인이 비공식적 경로를 통하여 소지인임을 주장하는 자로부터 연락을 받고 나서도 공시최고신청을 하여 제권판결을 받은 경우(대법원 1996. 8. 23. 선고 96다23900 판결) 등은 이에 해당되지 않는다.

한편 증서의 전 소지인이 그 증서의 현 소지인을 알면서도 그 소재를 모르는 것처럼 법원을 기망하여 제권판결을 받은 경우, 증서의 정당한 소지인이 제권판결불복의 소에서 패소하였는지 여부를 불문하고 전 소지인은 정당한 소지인에게 불법행위로 인한 손해배상책임을 질 수도 있다(대법원 1999. 5. 14. 선고 99다6463 판결).

## (8) 민사소송법 451조 1항 4호 내지 8호의 재심사유가 있는 때(8호)

### 다. 소의 제기와 접수

(1) 제권판결에 대한 불복의 소도 소의 일종이므로 그 제기절차는 제6장(접수사무)에서 설명한 바가 그대로 타당하게 된다. 따라서 반드시 서면에 의하여야 하며(소액사건이 되는 경우는 없다. 소액규 1조의2 참조), 소장의 필수적 기재사항을 명기하여야 한다.

또 인지도 통상의 소장에 준하여 첨부하여야 한다. 증권 등의 무효를 위한 공시최고에 따른 제권판결에 대한 불복의 소에서는 그 증권 등의 액면금액이 소송목적의 값이 되나, 액면이 없을 때에는 그 값의 산정불능으로 보아 그 값을 5,000만 원으로 보게 된다(인지 2조 4항, 인지규 18조의2). 제권판결에 대한 불복의 소의 피고는 공시최고신청인이다.

(2) 불복의 소에는 제소기간의 제한이 있다. 즉 원고가 제권판결이 있음을 안 날 또는 위 나.의 (4), (7), (8)의 경우에는 그 사유가 있음을 안 날부터 1월의 불변기간 내에 제소하여야 하며, 이를 알지 못한 경우라도 판결선고일 부터 3년이 지나면 제기할 수 없게 된다(민소 491조).

(3) 소장이 접수되면 민사사건으로 전산입력하고(인지액·편철방법예규) 제1심 민사 사건부호를 붙여 사건번호를 부여한 다음 민사 제1심 소송기록표지를 붙여 기록을 조제한다. 사건명은 ‘제권판결에 대한 불복’, ‘제권판결에 대한 불복의 소’로 하는 것이 보통이다.

(4) 관할은 공시최고법원(민소 490조 2항)에 속한다. 실무에서 흔히 문제 되는 것은 전술의 소송목적의 값이 5억 원을 초과하는 경우에 그 사건이 합의부 관할인지 단독판사 관할인지이다. 이론이 있을 수 있으나, 실무는 민사소송법 490조 2항에서 ‘최고법원’이란 공시최고를 한 법원, 즉 단독판사로서의 법원을 뜻하는 것으로 보아 소송목적의 값에 관계없이 단독판사가 관할함을 원칙으로 하고 있다.

## 라. 심리 및 재판

심리는 통상의 소와 동일하게 행하면 된다. 제권판결에 대한 불복의 소는 확정판결의 취소를 구하는 형성의 소로서, 소송경제를 도모하고 서로 관련 있는 사건에 대한 판결의 모순, 저촉을 피하기 위하여 다른 민사상 청구를 병합하여 심리판단할 수 있다. 예컨대 원고는 제권판결 불복의 소송절차에 피고가 공시최고신청을 하고 이에 따른 제권판결을 받는 일련의 과정에서의 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구를 병합할 수 있다(대법원 1989. 6. 13. 선고 88다카7962 판결). 다만 제권판결 불복의 소는 판결이 확정됨으로써 비로소 권리변동의 효력이 발생하게 되므로 이에 의하여 형성되는 법률관계를 전제로 하는 이행소송 등은 병합하여 제기할 수 없다. 예컨대 제권판결에 대한 취소판결의 확정 여부가 불확실한 상황에서 그 확정을 조건으로 한 수표금 청구는 허용되지 않는다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012다36661 판결).

제권판결 불복사건의 판결의 인용 시 주문은 다음과 같다.

### [기재례]

#### ① 민사소송법 490조 2항 1호의 경우

이 법원이 2025카공101호 공시최고신청사건에서 별지 목록 기재 증서에 대하여 2025. 10. 25. 선고한 제권판결을 취소한다. 위 증서에 대한 공시최고신청을 기각한다.

#### ② 민사소송법 490조 2항 2 내지 5호, 7·8호의 경우

이 법원이 2025카공2014호 공시최고신청사건에 관하여 2025. 10. 25. 별지 목록 기재 수표에 대하여 선고한 제권판결을 취소한다. 위 수표에 대한 제권판결신청을 각하한다.

#### ③ 민사소송법 490조 2항 6호의 경우

이 법원이 2025카공2014호 공시최고신청사건에 관하여 2025. 10. 25. 별지 목록 기재 수표에 대하여 선고한 제권판결을 다음과 같이 변경한다. 별지 목록 기재 수표에 대하여 원고가 신고한 권리를 보류하고 위 증서의 무효를 선고한다.